

第九章 前章の続き

一

これまでは法体系全体の長所や欠点が及ぼす影響を見てきたが、ここでは法体系の一部がもつ固有の性格による影響にも触れる。取捨選択が必要なので、いくつかの主要な論点に絞る。各国の民法のうち経済にとつてとりわけ重要なのは、労働者の身分を奴隷、農奴、自由人のいずれかに定める規定に次いで、相続と契約に関する規定である。さらに契約に関する法の中でも、経済上とりわけ重要なのは、組合に関する法と破産に関する法である。そして、これら三つの点すべてについて、イギリス法のいくつかの規定を非難する正当な理由がある。

遺産相続については、私は前章でこの問題の一般原則を示し、先入観を排して考えれば、法が採るべき最善の取扱いは次のとおりだと述べた。原則は遺贈の自由だが、制約は二点ある。第一に、子孫がいて自活できず、このままでは公的扶助によって国の負担

となる場合には、国がその子孫に給付することになる額に相当する分を遺産から留保し、子孫のために充てる。第二に、相続によつて一人が取得できる額は、中程度の自立に足る範囲を上限とし、それを超える取得は認めない。遺言がない場合は遺産の全体を国庫に帰属させ、そのうえで国は子孫に対し、正当で合理的な扶助を行う義務を負う。ここでいう扶助とは、親や祖先が本来行うべきだった内容を、子孫の事情や能力、育てられ方を踏まえて調整したものを指す。

相続法制は、現代の常識から大きく外れた考え方が真剣に検討される段階に達するまでには、なお幾つもの改良を重ねる必要があると思われる。その前提として、財産の承継方法には、認められている方式の中にも優れたものと劣るものがある以上、どれを優先すべきかを検討しなければならない。そこで折衷案として、英国の現行法が財産の相続について採用している、遺言がある場合には処分の自由を認め、遺言がない場合には均等に分割するという仕組みを、すべての財産に拡張することを勧めたい。ただし、傍系親族には権利を認めず、直系卑属も直系尊属もおらず、かつ遺言も残さない者の財産は、国に帰属させるべきである。

各国の現行法は、相続の基本原則から見ると、互いに反対の二つの方向へ偏っている。

イングランドや封建制の影響が残る国々では、土地などの不動産を大きなまとまりのまま維持することが重視され、遺言がない場合の相続は、地域によって慣習の違いはあるものの、原則として長男に限られるとされる。そして、形式上は所有者に遺贈の自由があるとされても、財産を特定の子孫の系統に拘束して承継させる仕組みを用いれば、直近の後継者に実質的に引き継がせないこともできる。この仕組みは、定められた方法以外での承継を妨げるだけでなく、売却もしにくくする。各代の保有者は終身の利益しか持たず、生存期間を超えて処分できないからである。これに対してフランスなどでは、法律は逆に相続財産の分割を強制し、遺言がなければ不動産か動産かを問わず子どもにも均等に分け、子どもがいなければ同じ親等の親族に均等に分ける。さらに遺贈の自由は認めないか、認めても一部に限られ、残りは強制的な均等分割の対象となる。

私の考えでは、これら二つの制度は、それが存在する国々において、正義に関する一般的な考慮や経済的帰結の見通しにもとづいて導入され、あるいは維持されているのではなく、主として政治的動機からそうなっている。具体的には、一方は巨額の世襲財産と土地貴族層を温存するためであり、他方はそれらを打ち壊し、その復活を防ぐためである。国策の目標としては前者はきわめて望ましくなくと思うが、後者については、私

にはそれを達成するよりよい方法があることをすでに指摘してきた。ただし、いずれの目的にも利点と欠点があり、その当否は政治学一般の問題であって、ここで扱うこの学の限られた領域の問題ではない。二つの制度はいずれも意図された目的に対する現実的で有効な手段ではあるが、どちらも、その目的を達するために多くの害を伴っているように私には見える。

一一

長子相続制を支持する経済的な議論は二つあるとされ、その一つは、年下の子どもを自力で身を立てさせることで、勤勉さや向上心を刺激すべきだという考え方である。ジョンソン博士は、世襲貴族を称賛するというより皮肉を込めて、長子相続制を勧める理由として「一家でばかりが出るのは一人で済む」と述べた。貴族制度の擁護者が、努力の必要を失わせるほどの相続財産は、一般に活動力や精神の強さにとって致命的だと主張した点は興味深いし、現代の教育水準を前提にすれば、誇張を差し引いても一定の説得力はある。けれども、その理屈を認めるなら、特定の長子だけに巨額を与えるのではな

く、長子を含む子ども全員の相続をわずかな扶養にとどめるべきだという結論に傾き、博士の言う「一家でばかりが出るのは一人で済む」という理屈自体も不要になってしまう。不労の富がそれほど有害だというなら、年下の子をその毒から遠ざけるために、それぞれの取り分を一つにまとめ、選ばれた一人に最大量を飲ませるしかない、という説明は腑に落ちない。巨額の財産をどう扱うべきか分からないからといって、長男にだけこの大きな害を負わせる必要はない。

ただし一部の論者は、長子相続制が勤勉さを促すのは、下の子どもが貧しくなるという事実そのものよりも、下の子どもが貧しさと長子の富との対比が人々を動かすからだと考えている。働きバチに蜂蜜の利点を十分に意識させるためには、とどころに巨大な雄バチがいることが巣の活動と活力に不可欠だ、という理屈である。マカロツクは、下の子どもは「財産面での劣位」と「その低い地位から抜け出し、兄たちと同じ水準に達したいという願い」によって、ほかの状況では得られない活力と精力を得ると述べている。さらに、平等分割によって大土地が細分化されるのを防ぐ利点は、所有者の下の子どもへの影響にとどまらないとして、「社会全体の生活水準を押し上げ、産業を動かす力に新たな勢いを与える。大地主の暮らしぶりは、誰もがいつかはそうできるように

なりたいと望むものであり、その支出の習慣は、ときに本人には不利益であっても、ほかの階層の創意や企業心を強く刺激する。人々は、最も富裕な地主の華やかさに並べるのでなければ、自分の財産は十分ではないと考える。こうして長子相続制は、あらゆる階層をいつそう勤勉にし、同時に富の総量と享樂の水準を高めるように見える」としている。

これらの指摘にどれほどの真実が含まれているかは私には断言できないが、そこから想起されるのは、財産が完全に平等な社会では、富を増やそうとする積極的な努力が促されにくい、ということである。一般に、財産についても、才能や知識や徳と同様、すでにそれを持つ人、あるいは隣人と同程度は持っていると思う人は、さらに多くを得ようとして努力することがめったにない。だが、それを理由に、向上心ある貧しい人々が羨望と尊敬の目で見上げる対象として、社会が大資産家の一群を用意する必要はない。人々が自力で築いた財産があるだけで、その目的は十分に果たされ、むしろそのほうが効果は大きい。というのも、ただ財産を持っている人の姿を見るより、財産を稼いだ人の実例のほうが、より強く人を刺激するからである。前者は勤勉さに加えて用心深さや儉約の手本にもなるのに対し、後者は相続などで財産を持つだけであることが多く、

浪費の見本になりがちである。その悪影響は、心の弱さと虚飾の好みのために「最も富裕な大地主のきらびやかさ、華やかさ、輝き」に強く引き寄せられやすい、まさに富の光景が有益だとされる層にまで及びうる。米国では世襲財産はほとんど見られないが、それでも産業の活力や蓄財への熱意が、特に乏しいとは見なされていない。ひとたび国が産業の道に本格的に踏み出せば、産業は現代の主要な営みとなり、古代や中世における戦争がそうであったのと同じく、勤労による獲得欲を人為的に刺激する必要はなくなる。富そのものに本来備わる利点に加え、富が才能や人生の成功を測る基準として日常的に扱われることが、十分な強さと熱意をもって富が追求されることの確かな保証となるからである。さらに、より深い考察として、望ましいのは富の集中ではなく分散と行き渡りであり、少数の巨富を万人が羨み渴望する社会ではなく、できるかぎり多くの人がほぼどの生活基盤を持ち、それに満足し、誰もが獲得できると望みうる社会のほうが健全だ、という見方もあるが、ここでは、社会問題に関する長子相続制の擁護者の思考様式が、本書で一部述べている立場といかに大きく隔たっているかを示すためにのみ触れておく。

長子相続を支持するもう一つの経済的議論は、とりわけ土地財産に関するものである。

すなわち、子どもたちに相続財産を均等に、または均等に近い形で分ける慣行は、土地を細分化し、採算よく耕作できないほど小さな区画を増やす、という主張である。しかし、この議論は繰り返し持ち出されてきたにもかかわらず、イングランドやヨーロッパ大陸の論者によって再三反論されてきた。というのも、それは政治経済学の諸定理が依拠する前提とまったく相いれない想定に基づき、人びとが差し迫った明白な金銭的利益に反する行動を、習慣的に選ぶと仮定しているからである。実際には、相続分を分けることは土地そのものを物理的に分けることを必ずしも意味しない。土地は共同で保有することもできるし、フランスやベルギーでしばしば見られるように、共同相続人の一人が土地を取得し、抵当などによって他の相続分を負担することもできるし、売却して代金を分けることもできる。土地の分割が生産力を下げる場合には、相続人にとってこれらの取り決めのいずれかを選ぶことが、そのまま直接の利益になる。それでもなお、この議論が想定するように、法的な困難のため、または当事者の愚かさや野蠻さのために、相続人が自分たちに任せられているならばこの明白な利益の命ずるところに従わず、土地を実際に等分に切り分けて困窮するのだとすれば、それはフランスにある強制分割の法律への反対理由にはなるが、遺言者が平等の原則におおむね従って遺贈する権利の行

使を一般に思いとどまらせる理由にはならない。遺言者には、相続分の分割が土地そのものの分割を伴わないよう、あらかじめ定めておくことが常に可能だからである。均等分割の慣行に不利な事実を挙げて長子相続を正當化しようとする擁護者たちの試みが同様に成果を上げていないことは、すでに別のところで示したとおりである。相続分の分割が小規模保有を伴って見られる国や地域があるとしても、それは小規模保有がその国の一般的な制度であり、大地主の所領においてさえそうであるからにすぎない。

長子相続制は、社会的有用性があるという強い根拠が示されないかぎり、たまたま長子として生まれたという偶然だけに基づいて人の扱いに大きな差をつける制度であり、正義の一般原則から見てもそれだけで十分に非難される。したがって、経済的な害をあらためて立証する必要性は高くはないとも言えるが、実際には弊害もはつきりしており、この制度が招きやすいのは地主階級の慢性的な資金不足である。土地を大きなまとまりのまま維持することが目的で、実際にそうなる例は多いものの、大領地の法的な所有者が、その土地が生む所得全体を自由に使える正当な受益者であるとはかぎらない。所得は各世代で、ほかの子への扶養や分与といった負担によって拘束されやすく、当主の無計画な支出によって、さらに重い負担がのしかかることも少なくない。大地主は収入が

多い時期にはそれに合わせて支出を増やし、事情が変わって収入が減っても節約に踏み切るまでに時間がかかりがちである。ほかの階層の浪費家であれば破綻すれば社会から姿を消すが、地主の場合は債権者のために地代を受け取るだけの立場に落ちても、土地を手放さずに抱え込みがちである。体面や家の華やかさを保ちたいという意識が、土地の一部を売って残りを抵当から解放する判断を鈍らせ、見かけの資力が実際の資力を恒常的に上回るため、実力以上の支出に傾きやすくなる。その結果、大地主のいる国では土地財産の大半が深い抵当に入っており、改良に回せる資本の余裕が乏しく、富と人口の急増で地価が上がっても、その増加分の多くが地主階級の貧窮化を防ぐために吸収されてしまう。

三

一家の没落を防ぐため、当時はエンタイル（限定相続）が用いられた。相続の順序を変更できないように固定し、各保有者の権利を終身に限ることで、後継者に負債を負わせられないようにしたため、土地は負債のないまま相続人に移り、一家は当代当主の放

漫さで没落しにくくなった。だが、この制度が生む経済的な害は、長子相続に伴う害と重なる面もあれば異なる面もあり、全体としてはより大きかった。保有者は後継者を破産させるほどの負債を残せない一方で、自分自身が破産する可能性は残り、土地改良に必要な資金も従前より調達しやすくなるわけではない。たとえ資金があっても、改良の利益は自分ではなく、エンタイルによって自分から独立した将来の相続人に帰属してしまい、年少の子どもたちを養っていてもその子どもたちのために地所に担保を設定できない以上、改良に資金を投じる動機は弱まる。さらに、エンタイルが譲渡を妨げるため、改良できる人物に地所を売ることも難しい。多くの場合、保有者は自分の存命中を超える期間の賃貸借契約すら結べず、ブラックストンは「もしそれが有効なら、長期賃貸借を隠れみのにして、子孫が事実上、相続から外されかねない」と述べた。こうした事情からイギリスでは、長期賃貸借を認めたり、地所を担保に資金を借りて改良できるようにしたため、制定法によってエンタイルの拘束を緩める必要があった。加えて、相続人は能力が乏しくても家産の承継が約束され、幼いころからそれを当然と思って育つため、怠惰や放縦、不行状に流れるおそれも大きい。

イングランドでは、相続財産を特定の家系に固定するエンタイルの効力は、スコット

ランドや同制度が残る多くの国々に比べて、法律上かなり強く制限されている。地主は、証書を作成する時点で生存している人物であれば人数の制限なく順に相続人として指定できる一方、まだ出生していない人物を指定できるのは一人までであり、その出生前の相続人が二一歳に達した時点でエンテイルは終了し、土地はその者の完全な所有となる。この仕組みにより、証書作成時に生きている息子、または息子と孫を経て、孫の出生前の子どもへ不動産を承継させることも可能である。この権限は、害が生じるほど広いものではないという見方もあるが、実際の影響は見かけ以上に大きく、エンテイルが期間満了でそのまま終了する例はほとんどなく、最初のエンテイル相続人が成人すると、現所有者と共同で不動産を再設定し、拘束をさらに一定期間延長するのが通例になっている。その結果、大規模な土地は厳格な相続設定の制約から長期間にわたって解放されないが、次の世代に向けて再設定する際に、年少の子どもたちへの給付分を不動産の負担として組み込むことが一般的であり、その点では弊害が和らぐ場合もある。

経済の観点から最も望ましい土地所有制度とは、土地が市場で十分に取引の対象となり、買い手が見つかって、その買い手が提示できる価格が、現所有者がそこから得ている収益の価値を上回るときには、所有権が滞りなく移る仕組みである。ここでの土地

は、費用を生むだけで利益を生まない裝飾的な不動産ではなく、産業に用いられ、そこから得られる収入を目的として保有される土地に限られる。土地の売買を容易にする制度は、社会全体にとって土地をより生産的な手段とする一方、売買を妨げたり制限したりする制度は、その有用性を損なう。こうした効果は、譲渡制限付きの世襲制度であるエンタイルにとどまらず、長子相続にも見られる。生産性を高めるという動機とは別の理由から、土地を広くまとめて持ち続けたいという人々の欲求が、土地の効率を高めるはずの売却や所有権の移転をしばしば妨げている。

四

他方で、フランスの制度に見られるように、遺贈の権限を狭い範囲に制限し、財産の全部または大部分を子どもに均等に分けることを法律で強制する仕組みには、理由は異なるにせよ、やはりきわめて重大な欠点があるように思われる。子どもが人生の出発に必要な扶助を超えて取り分を求めうる根拠があるとすれば、それは親の明確な意思、または事情から推定できる意思に求めるべきであって、現に親のものである財産をどう処

分するかという親の権限が、他人が自分のものではないものを受け取るべきだという主張によって退けられるべきではない。子どもに親の意思に優越する法的権利を与えて遺贈の自由を縛ることは、実在する権利を後回しにし、架空の権利を優先することになりやすい。さらに、この法律に対する重大かつ根本的な反対理由に加えて、多くの副次的な反対理由も挙げられる。親が子どもを公平に扱い、長子やお気に入り子を特別扱いしないことは望ましいにせよ、公平な分け方が常に均等分割と同義とは限らない。事情によっては、本人に落ち度がなくとも自立が難しい子もいれば、本人の努力以外の手段によってすでに基盤が整っている子もあり、その場合、公平のために必要なのは等分ではなく補償ということもある。仮に等分が目的であっても、法律が必然的に従わざるを得ない硬直的な規則より、等分を達成するのに適した方法がある場合もある。もし共同相続人の一人が争いを好み、権利の限界まで主張して譲らないなら、法律は公平な調整を行えず、関係者全体の利益にかなう配分もできない。土地が複数に分かれていて相続人がその評価で合意できなければ、法律は各人に一筆ずつ与えることができず、各筆は売却が分割に追い込まれる。住居や公園、庭園のように、分割によってその性格が失われてしまう資産がある場合には、金銭面でも心情面でも大きな犠牲を払って売却せざるを得

ないこともある。しかし、法律にできないことも親にはできる。遺贈の自由があれば、これらの点を、理性と当事者全体の一般的利益に照らして定めることができるし、遺言者が形式的な均等という文言に縛られない分、均等分割の原理の趣旨も、かえってよりよく実現できる。最後に、このような強制制度の下で必要となるように、親が生前贈与その他の生前の処分によって相続人の法定の権利を潜脱しようとする試みを防ぐために、法律が死亡時だけでなく生前から継続的に個人の事情に権威的に介入し続ける必要もなくなる。

結論として、財産の所有者は、自己の財産のすべてを遺言によって処分できるべきだと私は考える。ただし、遺言を作成した時点で存命だった者が全員亡くなったあとの承継者まで指定する権限まで認めるべきではない。ある者に終身の権利を与え、その残余をすでに存在する別の者に帰属させる遺贈を、どのような制限のもとで許すべきかは、政治経済学の問題ではなく、一般立法の問題である。なぜなら、このような取り決めは共同所有の場合と比べても譲渡をとくに妨げるものではなく、その財産について新たな取り扱いを定めるために必要なのは、現に存在する当事者の同意だけで足りるからである。

五

相続の議論を終え、私は話題を契約へ、さらに契約のうちでも重要な組合に関する法制度へと移す。協同の原理が現代産業にとって大きな経済的要請である以上、組合に関する法律が社会にもたらす影響がどれほど大きいのか、またその制度が可能な限りよいものであることがどれほど重要かは明らかである。生産技術が進むほど、産業はより大きな資本での運営を求められ、小資本を集めて大資本をつくることを妨げる要因があれば、その分だけ生産力は損なわれる。必要な規模の資本が単独の所有者に属する例は、多くの国で必要だけでなく十分に存在するとはいえず、法律が財産の集中ではなく分散を優遇するなら、そのような大資本はいっそう少なくなるだろう。他方で、大きな資金によって可能となる工程の改良や生産の効率化、費用節減が、資力が中程度ないし小さい人々が資本を結集しにくいという理由だけで少数の富裕層に独占される事態は、きわめて望ましくない。社会が賃金を支払う側と受け取る側に完全に分かれ、前者が一、〇〇〇人単位、後者が一〇〇万人単位という構図に固定される産業体制は、長期にわたって維持しにくく、無期限に続けられるものでもない。この仕組みを、依存を伴わない結合と利害

の一致を土台として、組織的な対立に代わる形へ転換できるかどうかは、今後の組合原理の発展にかかっている。

しかし、多数のパートナーによる結社の成立に対して、重大な、しかも多くの場合は意図的な障害を法律で設けていない国は、ほとんどない。英国でも、パートナー間の争いが実際には大法官裁判所でしか裁けないという事情は、それだけで強い抑止となつているうえ、そうした争いをいつそ法の外に置くよりも、しばしば害が大きい。というのも、当事者のうちに不誠実な者や訴訟好きの者がひとりでもいれば、他の者たちを思うままに訴訟へ引き込み、費用や手間、精神的負担といった大法官裁判所の訴訟に伴う重荷を負わせられ、しかも結社を解散してもその苦痛から逃れにくいからである。さらに、ごく最近まで、株式会社のような組織が適法に自らを組成し、団体として行動する権限を得るには、案件ごとの立法措置が必要だった。数年前の法律でこの要件は撤廃されたものの、その法律は有識者から「混乱の塊」と評され、パートナーシップに入る人々から「これほどの苦痛はかつてなかった」とまで言われている。少人数であれ多数であれ、共通の事業のために資金を自由に持ち寄り、特別な特権も他人の財産を奪う権限も求めないのであれば、法律が計画の実現を妨げる正当な理由は見当たらない。公示などの簡

単な条件を満たしさえすれば、どのような人々の集まりでも、公的職員や議会の許可なしに株式会社や合名会社を組成できるべきである。また、多人数の結社は実務上、少数の管理者の下で運営される以上、その少数が構成員であれ雇われた使用人であれ、結社全体が必要な統制と監督を及ぼせるよう、制度はあらゆる便宜を与えるべきだが、この点で英国の制度はなお理想から嘆かわしいほど遠い。

六

イングランド法は、通常のパートナーシップの原則に基づいて結成される団体にさまざまな便宜を与えていたとしても、一八五五年までは、ある種の株式会社形態の団体を絶対に認めず、それを成立させるには議会または国王による特別法が必要であった。すなわち、有限責任の団体である。

有限責任の組合は、大きく二つの型に分けられる。ひとつは組合員全員の責任を出資額の範囲に限る型で、これはフランス法の「ソシエテ・アノニム」に相当し、イングランドでは近年まで「チャータード・カンパニー」と呼ぶほかなかった。これは国王の勅

許、または議会の特別立法によって設立される株式会社を指し、株主は出資額を超えて会社の債務について責任を負わない仕組みとされてきた。もうひとつは、組合員のうち一部だけ責任を出資額の範囲に限る型で、フランス法で「コマンディット」と呼ばれる類型に当たるが、イングランドでは現在も制度として認められておらず違法とされているので、これについては後ほど述べる。

一定数の人々が商業や工業の事業を共同で営むために組合をつくり、構成員の責任は引き受けた出資額を上限とすると互いに取り決め、その条件を取引相手にも明示しているのに、法がこれに異議を唱えて当事者の望まない無限責任を負わせる理由はどこにあるのか。仮に守るべき相手がいるとしても、それは構成員ではなく第三者、すなわち当該組合と取引し、出資額を超える債務を負うおそれのある相手だ、という説明は一応成り立ち得る。しかし、そもそも誰にもその組合と取引する義務はなく、まして無制限の信用を与える義務もないから、虚偽の表示がなく、最初から自分が何を担保として信用を与えるのかを理解できる限り、法が当事者以上に相手方の利益を守る必要は大きくないと言える。法が正当に求め得るのは、有限責任会社や株式会社などについて、掲げる資本が実際に払い込まれているか、あるいはそれに対する担保が差し入れられているか

を確かめさせることに加え、個人が閲覧でき、必要に応じて公表もできる会計や帳簿を整えさせて会社の現状を随時確認できるようにし、唯一の担保である資本が損なわれずに維持されているかを把握できる仕組みを備え、さらに帳簿や会計の正確さを十分な罰則で担保することだと整理できる。法がこのように、会社と取引するに当たって個人の慎重な判断に必要な事情を知るための、実行可能な手段をすべて与えるなら、この種の取引についてだけ個人の判断に立ち入る必要が、ほかの私的取引や私的な経済活動より大きいとはいえないだろう。

有限責任の組合や会社に規制や公的介入が必要だと考えられがちなのは、運営者が損失を出しても全財産を失わない一方、利益が出れば大きな取り分を得られるため、十分に慎重に運用しようとする利害関心が薄れ、組合や会社の資金を不適切なリスクにさらしやすいと見なされるからである。もっとも、無限責任の組合や会社であっても、富裕な出資者や株主がいれば、取引が無謀だと知られていても不釣り合いに大きな信用を得ることがあり、その信用の規模は、債権者が払込資本だけを当てにする同程度にすぎない会社を与えられる信用を大きく上回る場合がある。害悪の天秤がどちらに傾くにせよ、これは第三者よりも株主自身にとって重大な問題である。なぜなら、適切な情報公開が

確保されていれば、有限責任会社の資本が通常の事業リスクを超える危険にさらされるなら、その事実は知られることになり、論評などによって、その会社の信用は事情に応じて相応に左右されやすいからである。さらに、情報公開を前提とするなら、無限責任を原則とする会社のほうが実務上より巧みに、より慎重に運営されることが確認されれば、有限責任会社は同じ条件では対等に競争できず、必要な資本を集めるうえで有限責任が唯一の条件となる場合を除いて、ほとんど設立されなくなるだろう。そしてその場合に設立を妨げるべきだと言うのは不合理であり、理屈にも合わない。

さらに言えば、資本額が同じであれば、有限責任会社は無限責任会社に比べて取引先に与える信用がやや低いものの、それでも、その弱いほうの信用でさえ、個人資本家が与えうる信用をいくつかの点で上回る。個人の場合、無限責任にもとづく安心感は期待できる一方で、取引内容の公開や、払込資本金が多額であることが広く知られていることに由来する安心感は得にくい。この点については、一八四三年七月号の『ルヴュ・デ・ドウ・モンド』に掲載されたコ克蘭のすぐれた論考で適切に論じられている。

個人と取引する第三者は、その相手が契約を履行できるだけの資本をどれほど持つかを正確には把握しにくく、せいぜい概算にとどまり、その概算もきわめて曖昧で不確か

なことが多い。これに対して株式会社と取引する場合は、求めれば十分な情報を得られ、個人取引では得にくい確信を持って業務を進めやすいという。また、個人商人は自分の負債や約束の範囲を隠しやすく、それを確実に把握しているのは本人だけで、信頼している事務係でさえ把握していないことがある。借入の中には日々の帳簿に記載する必要のない性質のものもあり、実態は本人の秘密となつて外部に伝わりにくく、伝わるとしても遅れて、破綻が起きてから明らかにすることが多い。一方、株式会社は借入をすれば取締役や事務員、株主、さらには公衆にまで事実が知られずに済むことはなく、そもそも知られないままであるべきでもないと言われる。株式会社の業務は一部で政府の事務に似て公然とした形で進み、情報を求める者に対して秘密を成り立たせにくいからである。こうした違いから、株式会社では資本と負債の全体が確定し記録され把握されやすいのに対し、個人商人では不確実で不明なままになりやすいとして、取引相手の立場から見てどちらがより有利な見え方を示し、より確かな保証を提示するのが問われている。

私企業の商人は、取引の実態が外から見えにくいという不透明さを利用し、さらにそれを強めることで、商売が順調に見えるうちは実力以上の資力があるかのような印象を

与え、資力に見合わない信用を築いてしまうことがある。損失が出て破産が迫っても世間はなお状況を把握しにくく、本人は返済できない水準まで借り入れを膨らませることができてしまう。破綻が表面化した時点で、債権者は想定を大きく超える債務を突き付けられる一方、返済に充てる資力がいつそう乏しい現実を知ることになる。さらに、この不透明さは信用の水増しにとどまらず、資本の一部を債権者の手の届かないところへ移す機会も与えるため、資本は目減りし、ときには失われたも同然となる。隠された資本は、法的手段を尽くしても、また債権者が追及しても、隠し場所から引き出せないことがある。こうしたことが株式会社でも同じ程度に容易だとは言い切れないが、起こりうることは自体は否定できず、ただしその性格や組織、そして各行為に伴う必要な公開性を踏まえると、発生しやすさは大きく下がると考えられる。

イングランドを含む多くの国の法律は、株式会社に関して二つの誤りを重ねてきた。すなわち、有限責任の結社については、その設立や存続を認めることに不合理なほど警戒してきた一方で、この種の共同事業が生みうる危険から社会を守るうえで最も有効な手段である情報公開を、十分に徹底してこなかったのである。しかも情報公開は、一般には認めないにもかかわらず例外的に存立を許された同種の結社であっても、同じ水準

で求められるべき安全策だった。立法府から独占権を与えられ、流通貨の状態という公共的関心の高い事柄について一部の統制権限を持ってきたイングランド銀行でさえ、情報公開が義務づけられるようになったのはここ数年にすぎず、その開示内容も当初はきわめて不十分だったが、現在は実務上の多くの目的にとって、おおむね十分な水準に達していると考えられる。

七

次に取り上げるもう一つの有限責任の組合形態は、事業を運営する組合員が当該事業の契約上の義務や債務について全財産をもつて責任を負う一方、これに参加する他の組合員は定められた一定額のみを出資し、その額を超えては責任を負わないという仕組みである。ただし、これらの組合員も、当事者が合意した任意の基準に従って利益に参与する。これはコマンドイト組合と呼ばれ、有限責任の組合員はコマンディテールとされる。フランス法では、コマンディテールが事業運営に一切関与することは禁じられている。これに対し、イングランド法ではこの種の組合は認められておらず、あらゆる私的

な組合において、利益を受け取る者は誰であっても、事業を運営する組合員と同様に債務について全面的な責任を負う。

このような禁止については、私の知る限り、これまで十分に納得できる弁護はなされていない。株式会社における株主責任の限定を批判する際に挙げられる不十分な理由でさえ、ここには当てはまらない。事業の運営に少しでも関与する者は全財産で責任を負うので、慎重な経営を促す動機が弱まることはないからである。第三者、とりわけ債権者にとっても、コマンディットの存在によって担保は強化される。コマンディテールが出資した額は全額が債権者の回収に充てられ、債権者が一円でも損失を被る前に、コマンディテールは投じた資本を全額失うからだ。これを出資ではなく、そこから得ていた利益と同程度の利子で貸し付けていたなら、出資者はほかの債権者とともに破産財産の残余に加わって配当を受け、配当率をその分だけ下げかねない。コマンディットの慣行はこのように債権者の利益に資するだけでなく、当事者自身にとってもしばしばきわめて望ましい。経営者は、自らの信用力を超える資本援助を得やすくなり、出資者も、企業の成否に全財産を賭けることが賢明でない、またはしばしば賢明にはできない場合でも、限られた額の資本を投じて有用な事業を支える道が開かれる。

株式会社を設立しやすい制度が十分に整っていれば、コマンディート型の有限責任組合は不要だと思われがちだ。しかし、状況によっては株式会社の仕組みよりもコマンディートの原理のほうが常に適しており、株式会社で置き換えるのは難しいとコ克蘭氏は指摘する。たとえば、発明家が発明を実用化するための資本を求める場合、資本家の協力を得るには将来得られる利益の一部を示し、成功の可能性をとみにし、リスクも分かち合ってもらう必要がある。だが、発明が失敗すれば全財産を危険にさらしかねない資本家を見つけるのはとりわけ難しく、このような場面で通常のパートナーシップが選ばれることはまずないという。また株式会社も、発明家が経営者の地位から追われるおそれがあり、ほかの株主と同じ一人の株主として群衆の中に埋もれてしまいかねないため、選びにくい。これに対して、組織がいわばその人のためにその人を中心として成り立っている形であれば、経営は当然その人の権利として担うべきものだと思なされやすい。こうした事情は発明家に限らず、商人や製造業者でも、事業の成功にとくに役立つ資質を備えているために、事業の運営を担う明確な理由がある場合に当てはまる。コ克蘭氏は、多くの場合に有限責任組合の必要性はきわめて大きく、それを不要として廃止したり、ほかの制度で代替したりするのは難しいと述べており、自国についてもおそ

らくそのとおりだとしている。

英国では、有限責任という制度的な後押しがなくても、一般の人びとが共同出資の会社をつくろうとする意欲と社会的な準備が大きいので、コマンディット型合資制度は、その禁止が原理上まったく弁護できないとしても、M. コ克蘭が言うほど、純粹に経済的な観点から見て不可欠で差し迫った必要があるとはみなしにくい。とはいえ、ある事業の利益を分け合うというだけで、だれもが無限責任の共同事業と同じ全面的な責任を負わされるという現行法の規定から、間接的に生じる不都合や不利益は小さくない。

このような法の状態によって、どれほど多くの、またどのような有用な結合の形が不可能にされているかを、数えることも特定することもできないが、少なくとも、賃金の一部を利益の一定割合として支払うこと、言い換えれば、労働者を資本家の事実上の共同出資者として結び付けることと両立しない以上、何らかの緩和は避けられず、現行制度には修正の余地がある。

とりわけ労働者階級の生活を改善し、社会的地位を高めるといふ点からいえば、協同事業や提携の条件について完全な自由を認めることが不可欠である。前章で述べた労働者協会のような結びつきは、労働者が自らの道德的資質を土台に社会的解放を実現する

ための最も有力な手段となる。結社の自由が重要なのは、成功例が示す効果のためだけではなく、失敗に終わる試みのためにも同じくらい重要だからであり、そうした失敗が、実地の経験にほかならない教訓にも劣らぬほど強く心に刻まれる学びを与えるからである。実験によって価値を確かめられる社会改善の理論は、その検証に付されることを認められ、さらには奨励されるべきである。そうした実験から、労働者階級のうち活動的な人びとは、自分たちの利益に反する利害や偏見をもつと見なされがちな人びとの教えからは、なかなか得られない教訓を引き出すだろう。さらに彼らは、社会に負担をかけることなく、自立を確立する手段について現在抱いている誤った考えを正す方法を得るだろう。そして、不正を伴わずに、あるいはそもそも実現するために、彼らが望む社会の再生に不可欠な道徳面、知的面、産業面の条件を見いだしていくだろう。

フランスの合名会社・合資会社に関する法律は、コマンディートを認めている点でイングランドより優れており、また商取引に伴う紛争が商人の法廷によって比較的安価かつ迅速に裁かれるため、大法官裁判所のような扱いにくい仕組みがない点でも優れている。しかし、それ以外の面では当時も現在も、制度全体としてイングランドに大きく劣っていた。有限責任の株式会社は、国務院という政府部局の明確な認可がなければ設立

できないが、同院は行政官が中心で産業や取引に通じない者が多く、事業を促進することに関心が薄い一方で、自らの役割を事業の抑制にあると考えがちである。そのため、認可の取得には企業開始の大きな障害となるほどの時間と労力を要し、そもそも認可が得られるかどうかの極めて大きい不確実さが、出資に応じようとする資本家を強くためらわせている。さらに、イングランドでは多数が容易に設立できる責任無限限の株式会社はフランスではそもそも認められず、無限責任の組合であつても、資本を譲渡可能な株式に分割することをフランス法は認めていない。

現存するパートナーシップ法制のなかで、最も優れているのはニューイングランド諸州の制度だとされる。ケアリーは、ニューイングランドほど結社が規制に縛られない地域はなく、その結果として結社活動が広がり、特にマサチューセッツ州とロードアイランド州では世界でも群を抜いていると指摘する。両州では、ほとんど考え得るあらゆる目的に対応する無記名会社、つまり認可法人が数多く設けられている。各町は道路・橋・学校を管理する法人であり、費用を負担する住民が直接統制するため、運営は良好だという。アカデミーや教会、公開講座団体や図書館、貯蓄基金組合や信託会社も、人々の需要に応じた数だけ存在し、いずれも法人化されている。各地区には地域規模に

見合う地元銀行があり、株式は近隣の小資本家が保有し、自ら運営するため、銀行制度が整い、融資額の変動も小さいとされる。その結果、銀行自身の動きに伴う通貨量や通貨価値の変化が資産価値に及ぼす影響も小さくなりやすいという。特にこの二州では、銀行はほぼ二〇〇行に達する。マサチューセッツ州だけでも、形態の異なる保険会社が五三社あり、州内各地に散在しているが、いずれも法人である。工場も法人化され、株式によって所有されており、原材料の購入から製品販売まで経営に関わる者は持分を持つ共同所有者となる。雇用される者もまた、慎重さと努力、儉約によって、将来は所有者になれるという見通しを持てる。慈善団体も多数あり、すべて法人である。漁船は操業者が持分で所有し、捕鯨船の船員の報酬はかなりの部分、場合によってはほぼすべてが航海の成否に左右される。南氷洋で取引する船の船長も持分所有者であり、その持分が努力と節約を促す強い動機となつて、ニューイングランドの人々は同地域の貿易で他国の競争相手を急速に押しのけつつあるという。彼らは移住先でも同様に協同して行動する傾向を示し、ニューヨークでは定期船航路の主要な所有者となつている。船は造船業者、商人、船長、一等航海士などが持分で所有し、航海士たちは一般に、いずれ自分も船長になれる資力を得ようとして励むため、これが彼らの大きな成功の理由だとされ

る。この仕組みは世界で最も民主的な制度であり、男女を問わず、すべての労働者や船員、工員に上昇の見通しを与え、その成果も実際に現れているとして、才能と勤勉、慎重さがこれほど確実に大きく報われる地域は世界にないと結んでいる。

欧州で多大な損失と大きな醜聞、非難を招いた米国の特許会社による支払い不能や不正の事例は、本抜粋が対象とする合衆国内のその地域では起きておらず、別の州で発生し、しかもそこに集中していたという。そうした州では、結社の権利が法的規制によってより強く制限されており、その結果、株式会社型の結社は、数でも種類でもニューヨークランドのものと比べられる状況にないとされる。ケアリー氏は、各州の制度を注意深く検討すれば、人々が結社の条件を自ら相互に定められるようにし、成立した結社が取引条件について公衆と契約や取り決めをできるようにすることから生じる利点は、読者にも疑いなく理解されるだろう、と付け加えている。そのうえで、構成員の責任が有限責任であれ無限責任であれ、その点は問題ではなく、関係しないと述べた。この原則は、当該分野に関する近年の英国立法全体の基礎として採用されている。

八

本節から、倒産法制を取り上げる。

この問題について適切な法律を整備することは、何よりも公衆道德の面で重要である。道德は良くも悪くも法律の影響を受けやすいが、なかでも金銭上の誠実さ、すなわち信用を保つことは、とりわけ法律の役割が大きい分野である。さらに経済の面から見ても、この問題は軽くない。第一に、国民の経済的な幸福と安定、ひいては世界と人類全体の繁栄は、契約や約束が守られると互いに信じられるかどうかに強く左右される。第二に、工業や商業などの産業活動には、いわゆる不良債権によるリスクや費用が伴い、これを抑えられれば生産費の引き下げに直結する。目的の達成に直接結び付かない支出項目を省けるためであり、その負担が個々の取引に固有であれば消費者が商品価格として支払い、広く共通するものであれば資本の一般利潤から差し引かれるにせよ、いずれにせよ社会のどこかが引き受けている。

この問題をめぐる各国の法律と運用は、歴史的に見ると、ほとんど常に二つの極端の間を振れ動いてきた。旧来の多くの国の法律は債務者への処罰が過酷で、債権者に強い

強制権を与え、支払い不能になった債務者に隠し財産の申告や引き渡しを迫ったり、支払いが得られないことへの腹いせとしてその権限を行使したりすることまで認めていた。国によっては、破産した債務者を債権者の奴隷として働かせることさえ許したが、労働によって債務を返済させる仕組みだと考えれば、わずかな合理性があったとも言える。

イングランドではこれより穏当で、強制は通常、投獄にとどまった。とはいえ、いずれも未熟な時代の乱暴な対策であり、正義にも人道にも反していた。しかし不幸にも、それらの見直しは刑法改革全般と同じく、正義の問題というより人道の問題として扱われがちで、当時の流行の人道主義が議論を一方向に偏らせ、旧来の厳罰への激しい反動として、他人の財産を失ったことや浪費したことさえ、寛大な扱いを受ける特別な理由になるかのような空気を生んだ。その結果、そうした事実に不利益を結び付ける規定は次第に緩められ、ついには撤廃されたが、放任がもたらす道徳的な弊害や規律を損なう影響が明らかになるにつれて、近年の立法は逆方向への、有益ではあるもののなお不十分な修正へと動くようになった。

返済できなくなった人に対して法が寛容であることは、支払い不能の場面で法が目指すのは債務者の身柄を拘束することではなく、財産を把握して債権者に公平に配分する

ことだ、という理屈で正当化されがちである。しかし、たとえそれが唯一の目的であり、そうあるべきだとしても、当初の法改正は緩和が行き過ぎており、かえってその目的を損ないかねない内容だった。債権者の裁量で債務者の投獄を求められる制度は、隠した財産や処分した財産を吐き出させるための有効な圧力でもあるのだから、この手段を奪った以上、改正法が十分な代替策を用意できているかどうかは、今後の運用で確かめるほかない。さらに、支払い不能者の財産を債権者へ移した時点で法の役割は終わりだという考え方は、見せかけの人道主義にすぎず、受け入れられない。法の役目は不正を防ぐことであり、起きてしまった不正の結果をその場しのぎで取り繕うことではない。支払い不能が金銭的に得をする投機にならないようにし、人が本人の知らないところで他人の財産を危険にさらして、成功すれば利益を取り、失敗すれば損失を本来の所有者に負わせるような振る舞いを許してはならない。債権者の金を私的な享楽に費やし、支払い不能になったほうが得だという状況も認めるべきではない。支払えないふりをする、いわゆる詐欺破産が発覚すれば処罰されるのは当然としても、実際に支払えないのだから不正行為の結果ではないと言い切つてよいのだろうか。債権者が優先的に請求権を有する財産があるにもかかわらず、浪費や賭博で散財した人が、金が消えたという事実だ

けで免責されるのは妥当なのか。道德の観点から、この行為と、詐欺や横領と呼ばれる不正との間に決定的な違いがあるのかが問われている。

この種の例は少数ではなく、支払不能の大多数を占める。破産統計を見てもその事実が裏づけられる。ある経験豊かな論者は、「支払不能の圧倒的多数は、看過できない不正行為に起因し、支払不能債務者裁判所と破産裁判所の手続記録を見れば明らかだ」と指摘したうえで、正当化しにくい過剰な取引や、値上がりすると思っただけで、なぜそう思ったのか自分でも説明できないような商品投機、ホップ、茶、絹、穀物など不案内な品目への投機、海外公債や株式会社への無謀な投資が目立つと述べ、しかもこれらは破産原因としてはまだ罪の軽い部類とした。さらに、彼が引用する経験豊かで賢明な筆者は、破産裁判所の複数の管財人の証言を引いて自説を裏づけている。管財人の一人は破産者から提出された帳簿や書類に基づいて一定期間の全件を整理し、「不案内な分野への投機で破綻したものが一四件、帳簿管理の怠慢が三件、資本と能力を超えた取引と、それに伴う融通手形の損失と費用が原因のものが一〇件、合理的に見込める利益を超える支出が四九件で、事業の収益自体はおおむね悪くなかった。全般的な不況や特定部門の取引減少によるものは一件もない」と説明し、別の管財人も一八か月で五二

件を担当した経験から「三二件は不分別な支出が原因で、五件はそれに加えて破産者が従事していた事業上の圧力もあった。残る一五件は無分別な投機で、多くは贅沢な生活様式を伴っていた」と述べている。

前掲の引用に加え、破産や支払い不能の多くは商人の怠慢や不精が招くとされている。帳簿を付けない、付けても不完全なまま決算で締めて照合せず、在庫も確認しない例が多く、取引が拡大して使用人を雇っても監督や管理を怠れば、結果として支払い不能に陥るという。ロンドンでは商業に携わる者の二分の一が棚卸しを一度もせず、毎年の損益や資金繰りを把握しないまま商いを続け、最後には学校の子どものように手元に半ペニーしか残っていないことを突然知って驚く、と述べられている。地方でも製造業者、商人、農民を問わず棚卸しをする者は四分の一に満たず、そのうち二分の一は備忘録程度の記録しか持たないという。さらに著者は、地方の小商人五〇〇人について十分に知っているとして、その五分の一は棚卸しをせず、基本的な勘定や帳簿すら付けていないと述べる。支払い不能の原因については、原因に疑いがある場合でも当事者に有利となるよう配慮して作成した表に照らすと、ぜいたくや不正が九件であれば、不運だけによるものは多くても一件にとどまると結論づけている。

もし法律が、このような手口を使う者に、不正行為の結果をその者を信用した人々に押し付けて自分だけが責任を免れることを可能にしているのだとしたら、取引に携わる人々に、強い正義感や名誉心、誠実さを期待するのは合理的だろうか。さらに法律が、そのようにして生じた支払不能を「不運」や「災難」とみなし、実質的に「違反ではない」「罪ではない」と告げているのではないか。

支払い不能や倒産は、債務者の力では避けられない事情によって起こることもあり、多くの場合、本人の責任が重大だと言い切れない事案も少なくない。法律はそのような事案を区別して配慮すべきだが、その前提として厳格で十分な調査が欠かせない。支払い不能という結果だけで手続きを終えるのではなく、何が支払い不能を招いたのかという原因を、可能な限り徹底して確認し、原因を特定しないまま処理を打ち切るべきではない。信用に基づいて金銭や金銭に相当する価値を受け取りながら、それを失ったり費消したりした以上、まず何らかの不正があったとみるのが自然であり、債権者に犯罪性の立証まで求めるのは適切ではない。実際には、債権者がそれを立証できるのは一〇件に一件もないことが多いため、その推定を覆す責任は債務者にあり、債務者は収支や資産、取引の全体像と経緯を開示して、不正がなかったこと、または不正があったとして

もやむを得ない性質のもので、酌むべき情状のある範囲にとどまることを示さなければならぬ。これができない場合、責任の程度に見合う処分を伴わずに免責するべきではないが、損害の回復に向けて努力して力を尽くす見込みが高いほど、処分は期間の短縮や軽減を認めてもよい。

支払い不能に関する法律は緩やかに運用すべきだと考える人たちの間では、大規模な商取引を除けば信用はむしろ害であり、債権者から法的救済の手段を取り上げれば信用供与を抑えられる、という主張がよく聞かれる。小売業者が生産性のない消費者に掛け売りを広げすぎれば、たしかに相当の害を招く。しかしこの害が問題になるのは、高額で、とくに長期の掛けに限られる。というのも、商品が店を出る前、少なくとも売り手の管理下を離れる前に代金が支払われない取引には必ず信用が伴うため、こうした信用まで一律に断てば不便が大きい。実際、支払い不能に関する法律が影響する債務の相当部分は、零細な商人が仕入れ先に負う代金であり、法の不備による規律の弛緩は、この分野でこそ最も有害に働く。これらの商業信用は、だれも縮小を望まないもので、国全体の産業を支えるだけでなく、資力が乏しくても誠実に商いを営む多くの人たちにとって不可欠である。それにもかかわらず、法が不正直または無謀な借り手に対する正当な

救済を備えていないために、必要な便宜を得ても乱用しない人たちが信用を得られなくなるなら、それは大きな損害となる。

即金払い以外の形で行われる小売取引が有害であり、立法によってそれを全面的に抑え込むことを目指してよいとしても、その実現手段として、信用してもらった者が罰を受けずに相手をだまして奪える余地を残すのは、目的の達成方法としてきわめて悪い。

法は、比較的落ち度の小さい者を罰するために人間の悪意を利用するものではなく、抑えたい行動があるなら制度として誘因と制裁を整えて抑止すべきであって、当事者を法の保護の外に置き、卑劣な者の略奪心に委ねるものではない。殺人者を死刑に処するとしても、金品目当てにその殺人者を殺した者を無罪にする制度を設けないのと同じである。他人の言葉を信じることは軽率だとしても、法に守られた詐欺師が勝ち誇って被害者を嘲笑する光景を各家庭の戸口にまで持ち込んでまで、そうした軽率さを思いとどまらせるほどの重罪ではない。ところが、支払不能に関する法制が緩和されて以降、このような有害な前例が現実にも広く示されてきた。仮に債権者から法的救済を一切奪ったとしても、問題とされる信用取引が大きく減ると見込むのは難しい。ならず者や詐欺師は依然として例外的な存在であり、人々はこれからも互いの約束を信じて取引するからで

ある。取引規模が大きく商売に余裕のある商人なら信用販売を断れるが、大都市の激しい競争の中や、村の小さな店の弱い立場では、一人の客が重要であり、開業して間もない商人に信用販売を避けよと言っても現実的ではない。売れなければ破綻し、だまし取られても破綻しかねない以上、危険が増しても引き受けざるを得ない。さらに、手を調べて掛けて売る相手を見極めよという助言も決め手にはならず、破産裁判所に持ち込まれた悪質な事案の中には、詐欺師が立派な紹介状を用意し、実際に提示していた例もあった。